

TENTATIVA

O Código Penal além de punir o crime consumado também pune a tentativa – quando o agente busca determinado resultado, mas não o alcança por razões alheias à sua vontade.

Algumas denominações que a doutrina utiliza para o termo “tentativa” são: *Conatus* (esforço, em latim), crime manco, crime imperfeito ou crime incompleto.

ATENÇÃO

Muitas vezes a banca examinadora utiliza a expressão “*conatus*” para se referir à tentativa.

CP, art. 14. Diz-se o crime:

Crime consumado

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena – de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.



5m

A tentativa pode ser vislumbrada desde o início até o momento posterior ao término dos atos executórios (fase externa) do *iter criminis*, desde que seja antes da consumação.

ROUBO – MOMENTO CONSUMATIVO

Súmula 582, STJ

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse manda e pacífica ou desvigiada.”

A Súmula 582 é importante para que se verifique que não é simples a transição entre a tentativa e a consumação do crime.

ANOTAÇÕES

Anteriormente havia teorias que apresentavam que a consumação ocorria, por exemplo, quando o agente apenas tocava no objeto do roubo, entre outras hipóteses. A Súmula apresentada entende que a consumação do crime de roubo ocorre com a mera inversão da posse da vítima para o agente.



ELEMENTOS DA TENTATIVA

1) Prática de Atos Executórios

Para que haja a tentativa é necessário que ocorra, pelo menos, o início dos atos executórios.

2) Ausência de Consumação por Circunstâncias Alheias à Vontade do Agente

3) Dolo Voltado para a Consumação do Delito

Para que se fale em crime tentado é importante verificar o dolo do agente para determinar a punição em cima da tentativa. Assim, nunca se fala em tentativa de homicídio se o dolo do agente não era voltado para o homicídio, por exemplo.

4) Resultado Possível

Se o resultado que se busca não é possível, não há que se falar em tentativa de crime.



NATUREZA JURÍDICA DA TENTATIVA

Causa Obrigatória de Diminuição de Pena

O ato de diminuição da pena é obrigatório, cabendo ao juiz apenas determinar o tempo dela (de um terço até dois terços).

Norma de Extensão ou de Ampliação da Conduta – Ampliação Temporal

Sempre que se imputa a tentativa ao agente se utiliza o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim, a tentativa terá uma tipicidade de subordinação mediata (ampliada ou por extensão), já que o crime consumado tem a subordinação imediata – aplicando-se apenas o artigo do caso.

Os tipos penais, salvo raras exceções, sempre trazem a modalidade consumada. Portanto, para se aplicar a modalidade tentada é necessário combinar o tipo penal de determinado crime com o artigo 14, inciso II (subordinação mediata).

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A norma é de extensão ou de ampliação de conduta porque não se amplia a conduta apenas para o crime consumado, mas também para a tentativa.

A ampliação temporal diz respeito ao fato de que se sai da punição da consumação e pune-se o que aconteceu antes, nos atos executórios. Logo, amplia-se no tempo a possibilidade de punir o agente, não apenas quando ele consome o crime, como também antes.

Se não existisse o artigo 14, inciso II, seria impossível punir qualquer pessoa pela tentativa do crime.

CP, art. 14, II – [Considera-se o crime] tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

PUNIÇÃO DA TENTATIVA



20m

Teorias

Nem todas as teorias são adotadas no Direito Penal Brasileiro. Há apenas uma teoria principal e uma outra que é adotada excepcionalmente.

Para alguns doutrinadores não deveria existir tentativa, sendo que o agente deveria responder pela tentativa com a mesma pena do crime consumado ou não, já que o que importa é a intenção do autor.

a) Teoria subjetiva, voluntarística ou monista

- Leva em consideração o dolo do agente.
- A punição do crime tentado deve ser a mesma do crime consumado.
- É possível a punição dos atos preparatórios porque eles já demonstram a intenção do agente.

b) Teoria sintomática

- Leva em consideração a periculosidade subjetiva do agente, em que a pena do crime consumado é aplicada também na tentativa, mas apenas para quem demonstra uma efetiva periculosidade.
- Essa teoria não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

c) Teoria objetiva, realística ou dualista

- Esta é a teoria adotada em regra pelo Código Penal Brasileiro.
- Leva em consideração a proximidade da consumação e a prática de atos executórios.

d. Teoria da impressão ou objetivo-subjetiva

- Corrobora a teoria subjetiva, com a única diferença de que limita o alcance aos atos preparatórios.

Qual teoria foi adotada, em regra, pelo Código Penal Brasileiro?

Em regra, o Código Penal Brasileiro adota a teoria objetiva, realística ou dualista.

CP, art. 14, Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

De acordo com a teoria objetiva, quanto mais próximo da consumação, quando iniciado os atos executórios, a tentativa será menor e, portanto, o agente deve sofrer uma punição mais grave.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TRF – 1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2017) Julgue o próximo item, relativo ao instituto da tentativa.

No que concerne à punibilidade da tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva.



COMENTÁRIO

Em regra, é adotada a teoria objetiva. Excepcionalmente, o Código Penal adotou a teoria subjetiva, voluntarística ou monista.

CP, art. 14, Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena corresponde ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Existem exceções em que o crime na modalidade tentada não terá a pena reduzida em relação ao crime consumado. Estas exceções são chamadas de crimes de atentado ou de empreendimento.

ANOTAÇÕES



CRIMES DE ATENTADO OU DE EMPREENDIMENTO

Estes crimes são punidos pela lei de maneira igual aos crimes tentados ou consumados.

Exemplos:

1) Art. 352, CP – (Evasão mediante violência contra a pessoa) “Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa: Pena – detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.”

Neste exemplo é aplicada a teoria subjetiva.

2) Art. 309, Código Eleitoral – “Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem: Pena – reclusão até três anos.”

Neste exemplo é aplicada a teoria subjetiva.

CP, art. 14, Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

COMO DEFINIR O QUANTUM DA DIMINUIÇÃO

ATENÇÃO

As provas cobram o conhecimento acerca do *quantum* da diminuição do crime na modalidade tentada. Por isso, lembre-se que a pena pode ser diminuída de um a dois terços.

Quanto mais próximo o delito chegar da consumação, menor será a diminuição.

Exemplo 1: na tentativa de homicídio em que a vítima não sofre qualquer lesão a diminuição da pena é maior (dois terços).

Exemplo 2: na tentativa de homicídio em que a vítima é atingida por um disparo de projétil no peito e fica 2 meses em coma a diminuição da pena será menor (um terço).

TENTATIVA E COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Os crimes cuja pena máxima não ultrapassam dois anos são julgados pelo Juizado Especial Criminal.

Exemplo: **Abandono de incapaz, art. 133** – Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

Pena – detenção, de seis meses a três anos.



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A pena deste crime na modalidade consumada é de seis meses (mínimo) a três anos (máximo). Na modalidade tentada, a pena passa a ser de, no máximo, dois anos.

Assim, se o agente responder por crime de abandono de capaz na modalidade tentada, o caso pode ser julgado pelo Juizado Especial Criminal.



DIRETO DO CONCURSO



40m

2. (VUNESP/PC-CE/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2015) Crime que tem reprimenda privativa de liberdade cominada de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos, após ter reconhecida a modalidade tentada e sem considerar qualquer outra majorante ou minorante, terá pena fixada entre os patamares mínimos de
- a. 4 (quatro) meses e máximo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.
 - b. 6 (seis) meses e máximo de 3 (três) anos.
 - c. 9 (nove) meses e máximo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.
 - d. 9 (nove) meses e máximo de 2 (dois) anos e oito meses.
 - e. 4 (quatro) meses e máximo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.



COMENTÁRIO

Primeiro, é preciso converter as penas mínima e máxima do crime em meses. Assim, 1 ano corresponde a 12 meses, e 4 anos correspondem a 48 meses.

Para saber a pena máxima, aplica-se a menor diminuição do caso tentado ($1/3$) para a pena máxima do crime (48 meses). Portanto, divide-se 48 por 3 e multiplica-se o resultado por 1; o resultado desta operação deverá ser subtraído da quantidade de meses da pena máxima. Para saber a pena mínima, aplica-se a maior diminuição do caso tentado ($2/3$) para a pena mínima do crime (12 meses). Assim, divide-se 12 por 3 e multiplica-se o resultado por 2; o resultado desta operação deverá ser subtraído da quantidade de meses da pena mínima.

GABARITO

- 1. C
- 2. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.